

第 53 問

F は、まとまった現金が必要となったため、自分が持っている美術品を売却することとし、美術品に詳しい知人の X に売却を依頼した。その際、売却の手数料は売却額の 15 パーセントと定めた。F が売却を依頼した美術品は①、②、③の 3 点で、そのうち③は実は 2 年前に自分が盗んだものであったが、こうした事情を X は知らなかった。3 点の美術品のうち、①と②については、美術品愛好家の A に予想以上の高値（合計 1000 万円）で買い取ってもらったが、借金に追われていた X は現金が欲しくなり、F には 700 万円で売れたとあって 700 万円から手数料 105 万円を差し引いた 595 万円を渡し、残りは自分の借金の返済にあてた。③については、B に 300 万円で売却することにし、代金を受領したが、その後知人 C から③は F が盗んだものであるとの話を聞き、受領した現金を着服しても、F の弱みを握った以上訴えられることはないと考えて、売却代金を F に手渡すことなく、自分の借金の返済に使った。

X の罪責について論じなさい。

（東京大学法科大学院 平成 21 年度 改題）

第1 美術品①・②について

- 1 Xは知人Fから依頼され、美術品①・②を合計1000万円で売却したが、実際には売却代金を700万円であると伝え、手数料15パーセント分を差し引いた595万円しか渡していない。本来は1000万円から手数料15パーセントを差し引いた850万円を渡さなければならないから、その差額分255万円について横領罪（252Ⅰ）が成立する可能性がある。

横領罪の成立要件は、①「他人の物」であること②「自己が占有する」こと③その占有が委託に基づくこと（委託信任関係）④その物を「横領」することである。

このうち、まず、①について、金銭の他人物性が問題となるが、判例は、民法と刑法で他人物性を一致させる必要は必ずしもないと考えている（最判昭26.5.25【百選Ⅱ64】等）（**論点**「他人の物」（252Ⅰ）の意義（寄託された金銭等） 司H19,予H27,旧H10-2,H14-2,H20-2）。

次に、②占有及び③委託信任関係は問題なく認められ、最後に実際の売却代金より少ない金額を伝えて、差額を着服しようとしているから、その時点で不法領得の意思（判例は、「横領罪の成立に必要な不法領得の意志〔ママ、以下同じ〕とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意志をいう」（最判昭24.3.8【百選Ⅱ66】）とする。）が発現したといえ、④「横領」行為の存在も認められる。

- 2 なお、売却代金を偽っている点が重ねて2項詐欺罪（246Ⅱ）を構成するかが問題となる（**論点**横領罪と2項詐欺罪の関係 司H19,旧H4-2,H10-2,H14-2）。この点は横領行為を完遂するための手段にすぎないとして、別途詐欺罪は成立しないと解するのが判例（大判昭11.10.19）・通説である。

 総合 239 頁  論証 111 頁

 総合 246 頁  論証 67 頁

第2 美術品③について

美術品③については、売却代金を全て着服していることが横領罪を構成する可能性がある。

①他人物性②占有については、上記同様問題ないが、③委託信任関係については問題がある。美術品③は盗品であり、委託者であるFに本権（所有権）がないからである。そのような場合でも保護すべき委託信任関係があるのが問題となるが、判例は、この点を肯定的に解するようである（最判昭36.10.10参照）（**論点**盗品（売却代金）の横領 司R4,予H26,旧H4-2,H14-2,H20-2）。

最後に④「横領」行為については、自分の借金の返済に使った時点で認められる。

なお、盗品関与罪の成立可能性もあるが、盗品であることを知ったのは美術品③を売却した後であるから、同罪は成立しない。

以上から、Xには美術品①～③の売却代金についてそれぞれ横領罪が成立し、全て併合罪の関係に立つ（45前段）。

 総合 240 頁  論証 112 頁

答案構成

第1 美術品①②の売却代金を着服した行為について

1 横領罪（252 I）の成否

↓
「占有」
↓
「他人の物」
↓
金銭の他人物性
↓
委託信任関係
↓
「横領」
↓
不法領得の意思（他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思）を実現する一切の行為

↓
横領罪成立

2 2項詐欺罪の成否

↓
横領罪一罪で処断される

第2 美術品③の売却代金を着服した行為について

1 盗品等有償処分あっせん罪（256 II）不成立

2 横領罪の成否

↓
「自己の占有する他人の物」
↓
窃盗犯Fとの委託信任関係は保護に値するか
↓
肯定説
↓
「横領」
↓
横領罪成立

第3 罪数

255万円についての横領罪及び300万円についての横領罪が成立し、両罪は併合罪（45前段）となる

第1 美術品①②の売却代金を着服した行為について

1 (1) ①②の売却代金のうち、Fに返還すべきである差額255万円をX
2 が着服した行為について、「自己の占有する他人の物を横領した」も
3 のとして、横領罪(252条1項)の成立が考えられる。

4 (2) まず、Xが着服した上記255万円は、Xが「占有」する物ではあ
5 るが、「他人の物」に当たるか。

6 この点について、民法上金銭については所有と占有が一致すると考
7 えられていることからすれば、金銭についてはおよそ「他人の物」に
8 は当たり得ないのではないとも思われる。

9 しかし、民法における所有と占有の一致の原則は、取引の安全を保
10 護するために認められるものであり、これを所有権の保護を図った横
11 領罪の解釈にそのまま持ち込むのは妥当ではない。

12 よって、金銭も「他人の物」といえる。

13 (3) また、条文上明らかではないものの、横領罪の成立には、占有離脱
14 物横領罪との区別の観点から、委託信任関係が要求されるところ、少
15 なくとも①②については盗品ではなく、保護に値する委託信任関係が
16 認められる。

17 (4) そして、「横領」とは不法領得の意思を実現する一切の行為であ
18 り、不法領得の意思とは他人の物の占有者が委託の任務に背いてその
19 物につき権限がないのに所有者でなければならないような処分をする
20 意思を指す。

21 本問では、XがFに実際の売却代金より少ない金額を伝えて、差額

1

2 を着服しようとした時点で、他人の物の占有者が委託の任務に背いて
3 その物につき権限がないのに所有者でなければならないような処分を
4 する意思、すなわち、不法領得の意思の実現が認められ、「横領し
5 た」といえる。

6 (5) よって、①②の売却代金から着服した上記255万円についてXに
7 横領罪が成立する。

8 2(1) 次に、Xが着服するために、1000万円でAに売れたにもかかわ
9 らず、700万円でしか売れなかったと嘘を述べて、Fから上記差額
10 の請求を免れた点について、「人を欺いて」(246条1項)「財産
11 上不法の利益を得」たとして、詐欺利得罪(同条2項)の成立が考え
12 られる。

13 しかし、この行為は、上記横領行為完成のための手段であるから、
14 別途詐欺利得罪は成立しないと解すべきではないか。

15 (2) この点について、横領行為の完成のための手段であったとしても、
16 欺罔行為により被害者からの請求を免れたことは否定できない。

17 しかし、横領罪は、物が自己の占有下にあることから奪取罪に比べ
18 て間接的な侵害であり、また、行為者としても誘惑的であって非難可
19 能性が少ないため、詐欺罪や窃盗罪に比して法定刑が低くなっている
20 のである。そうだとすれば、横領行為の完成のための手段としての欺
21 罔行為について、詐欺利得罪を成立させてしまうと、横領罪の法定刑
22 を低くした趣旨を没却させてしまい、妥当でない。

そこで、横領行為完成のための欺罔行為については、横領罪におけ

2

る領得行為の一部と考えるべきであり、別途詐欺利得罪は成立しないと解する。

(3) 本問でも、上記行為に詐欺利得罪は成立しない。

第2 美術品③の売却代金を着服した行為について

1 まず、盗品たる③をBに売却した行為については、盗品性の認識がないため、盗品等有償処分あっせん罪（256条2項）は成立しない。

2(1) 次に、盗品である③の売却代金300万円を自分の借金の返済に使った行為につき、横領罪が成立することが考えられる。

(2) まず、金銭が横領罪の客体となり得るのは、前述のとおりである。

また、③は盗品であって、少なくとも③の売却代金の所有権がXに帰属しないことは明らかであるから、「自己の占有する他人の物」の要件は満たす。

もっとも、③は盗品であるから、委託者であるFにも③の所有権は帰属しない。そうだとすると、このようなFとの委託信任関係は保護に値しないのではないか。

この点について、刑法の目的は、個人の法益保護にとどまらず、財産秩序の維持にあり、刑法における要保護性は民法とは別に考えるべきであるから、所有権を有しない者との間の委託信任関係もひとまず保護に値すると解すべきである。

(3) そして、当該300万円を自己の借金の返済に充てた時点で、不法領得の意思の実現が認められ、「横領」したといえる。

(4) 以上より、横領罪が成立する。

3

第3 罪数

Xの行為には、255万円についての横領罪及び300万円についての横領罪が成立し、両罪は併合罪（45条前段）となる。

以 上

4